

1500292-07.2022.8.26.0626

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIO DA SILVA BRANCHINI

Comarca: Caraguatatuba

Foro: Foro de Caraguatatuba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... a configuração de flagrante delito de tráfico de entorpecentes, tendo em vista que o próprio acusado teria informado que mantinha entorpecentes na residência, tendo franqueado a entrada dos policiais.

Como se sabe, em situações de flagrante delito como ocorre no caso de armazenamento de entorpecentes em residência, tendo em vista que o tráfico é crime permanente o ingresso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caraguatatuba - Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal

Praça Doutor José Rebello da Cunha, 73, Caraguatatuba - SP - cep 11660-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500292-07.2022.8.26.0626 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500292-07.2022.8.26.0626

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HERIK LEITE DOMINGOS

VISTOS.

HERIK LEITE DOMINGOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, e no artigo 12 da Lei n.º 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal. Segundo consta da denúncia e dos inclusos autos de inquérito policial, no dia 25 de junho de 2022, às 21h45min, na Rua Três, nº 07, Jardim Santa Rosa/Massaguaçu, o acusado trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 1.748 (mil setecentos e quarenta e oito) porções à vácuo de Cocaína, com peso total de 1.418,99g, e 83 (oitenta e três) pedras de Crack, com peso total de 75,04g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Auto de Exibição e Apreensão e Laudo de Constatação Preliminar juntados aos autos.

Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e no interior de sua residência, foi encontrada na posse de HERIK LEITE DOMINGOS uma arma de fogo calibre 28 de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Exibição e Apreensão juntado aos autos.

A denúncia foi recebida em 01 de julho de 2022 (fls.65/66). O réu foi citado (fl. 76) e apresentou resposta à acusação (fls. 81/82).

No curso da instrução processual, foram colhidos os depoimentos das testemunhas de acusação e de defesa, bem como o interrogatório do acusado, tudo por intermédio de sistema de teleconferência, constando as respectivas gravações armazenadas na mídia.

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram.

O Ministério Público apresentou alegações finais orais, pugnando pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição do acusado.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, analisando a preliminar arguida, entendo que não merece acolhida. Observa-se que a legalidade da diligência policial se encontra demonstrada nos autos, não havendo qualquer elemento capaz de infirmar suas alegações.

Não se olvida que a palavra dos agentes da lei pode ser contraditada, mas não da forma como pretende a defesa, sem indicação de elementos concretos contundentes, que justifiquem a impugnação formulada.

Acolher tais alegações seria conferir verdadeira presunção de ilegitimidade aos atos policiais em favor dos investigados, subvertendo-se o princípio da presunção de inocência.

Também deve ser afastada a alegação de inobservância da inviolabilidade de domicílio do acusado.

Isto porque, a partir dos relatos dos policiais tanto em solo policial quanto em juízo, infere-se que estes adentraram à residência do acusado pautados por fundadas razões que levavam a presumir a configuração de flagrante delito de tráfico de entorpecentes, tendo em vista que o próprio acusado teria informado que mantinha entorpecentes na residência, tendo franqueado a entrada dos policiais.

Como se sabe, em situações de flagrante delito como ocorre no caso de armazenamento de entorpecentes em residência, tendo em vista que o tráfico é crime permanente o ingresso das forças policiais no imóvel apenas será lícito se houver fundadas razões que corroborem, a priori, seu entendimento de que, no interior da residência pratica-se um crime. Entendo que, no presente caso, estavam presentes as fundadas razões acima mencionadas, tendo em vista que, em todas as ocasiões em que ouvidos, os policiais militares, em uníssono, confirmaram que o acusado havia indicado o próprio endereço como ponto de armazenamento de drogas. Sendo assim, presente o cenário fático excepcional que corroborava as suspeitas dos agentes de segurança quanto à presença de ilícitos no interior da residência.

Ressalte-se que a jurisprudência entende ser viável a busca domiciliar em casos de crimes permanentes sem mácula ao princípio da inviolabilidade de domicílio, nesse sentido:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2.

Inviolabilidade de domicílio - art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos - flagrante delito, desastre ou para prestar socorro - a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori.

Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.

6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e

penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016);

Assim, pautado por tais entendimentos jurisprudenciais, afasto a tese de violação à inviolabilidade de domicílio, mormente levando-se em consideração que, de fato, o acusado estava em posse de grande quantidade de entorpecentes, arma de fogo no interior da residência vistoriada.

Isto posto, afasto a preliminar arguida.

No mérito, a ação é PROCEDENTE.

a materialidade restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls.06/07) e demais peças que o acompanham, boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e apreensão (fl. 18), auto de constatação preliminar (fl. 20), laudos periciais (fls. 84/87 e 88/90) e demais provas produzidas nos autos.

A autoria está comprovada.

A testemunha e policial militar, DOUGLAS RODRIGUES BITTENCOURT DA COSTA, disse em seu depoimento na delegacia, que estava embarcado, juntamente com seu colega de farda, na viatura de prefixo I-20.091. Consta que por denúncia de que indivíduo estariam traficando com arma longa. Foram fazer averiguação. Consta que a viatura foi conduzida pelo motorista, pela via pública, sendo que o depoente e outro auxiliar (Sgt. JORGE) foi pela trilha. Que avistaram o investigado, e que este tentou empreender fuga, oportunidade em que foi alcançado. Que em revista pessoal, foi encontrado em seu poder uma sacola verde, contendo em seu interior, cerca de 35 "vácuo" (cocaína) e 22 (vinte e duas) pedras de crack. Que não portava documentos. Indagado sobre os fatos, informalmente confessou. Constava um outro indivíduo o qual conseguiu fugir, sendo que foi interpelado o investigado sobre este indivíduo, tendo este ficado calado. Em prosseguimento foi este indagado sobre mais entorpecentes, tendo este alegado que na residência em que residia, Rua CINCO - Morro do Chocolate -, haveria mais entorpecente. Que para o local foi feito o deslocamento até tal moradia, e ali embaixo da cama foi encontrado uma sacola, com grande quantidade de entorpecentes, as quais se tratam da mesma droga, pois apresentava embalagens semelhantes e individualização idênticas. Na referida residência foi localizada uma arma, debaixo do colchão em cima do estrado da cama. Indagado sobre os fatos, afirmou que estava traficando e que estava a pouco tempo em liberdade, por pratica de tráfico. Em juízo, prestou depoimento semelhante ao da fase policial.

A testemunha e policial militar, GEORGE ALVES DE OLIVEIRA, que também participou dos fatos narrados na denúncia, na delegacia prestou depoimento, também de maneira firme, corroborando a versão narrada por seu colega. Em juízo, prestou depoimento semelhante ao da fase policial.

Em seu interrogatório em solo policial o réu HERIK LEITE DOMINGOS negou estar traficando, bem como estar na posse da arma. Alega que foi até o local e lá estava fumando um "back". Alega que correu e foi encontrado debaixo de um veículo e que ali o detiveram. Alega que os policiais " cassaram" as drogas e encontrando disseram que iriam dizer que era do indiciado. " Falei para eles que não era minha", " Levei eles lá em casa, pois disseram que iriam me soltar se desse mais droga, e depois me trouxeram preso e apresentaram a arma que não vi eles encontrar, mas eles falaram que estava lá em casa". " Eu estou a uma mês solto, acabei de alugar a casa". Não tenho nada a ver com o presente caso". Em juízo, negou a prática dos delitos, alegando que os policiais teriam forjado a situação flagrantial.

Como se vê, o conjunto probatório é suficiente para condenar o réu pelos crimes descritos na denúncia. Isto porque, as declarações dos policiais e as demais provas nos autos demonstram a autoria delitiva.

No mais, destaque-se que foram apreendidos entorpecentes embalados e acondicionados em embalagens fracionadas, em quantidade incompatível com o uso, bem como significativa quantia em espécie, fato comum em ocorrências de tráfico de drogas. Quanto à prova oral, consigne-se que a impugnação à valoração do depoimento dos

policiais deve ser afastada, vez que inexistente qualquer elemento apto a sustentar a alegação de suspeição. Está pacificado na jurisprudência que a condição de policial seja militar ou civil, estadual, federal ou municipal, por si só, não invalida o seu testemunho, porquanto ele não está impedido de depor e se sujeita a compromisso como outra testemunha qualquer. Vejamos: "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal." (HC 146.381/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17.06.10, DJe 09.08.10).

Registre-se que, além de não demonstrado o interesse dos policiais em prejudicá-los, o depoimento deles "podem ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte". (STJ - HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005).

No mesmo sentido: "(...) Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (...)". (HC 223.086/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, C UINTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 02/12/2013).

Ainda, vale ressaltar que eventuais pequenas incongruências nas declarações são compreensíveis dado o decurso do tempo entre a abordagem policial e a realização desta audiência, contudo não são capazes de retirar a credibilidade dos testemunhos dos policiais militares.

Nota-se, portanto, que a traficância restou devidamente caracterizada, já que, conforme lição de Luiz Flávio Gomes, "Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (In EL TASSE, Adel et. al. Legislação Criminal Especial. Vl. 6. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 197).

Por fim, registro que o laudo pericial de fls. 84/87 atestou a potencialidade lesiva da arma, indicando que "A arma descrita, no estado em que foi apresentada para a Perícia, estava com defeito no mecanismo de disparo, de tal forma que o gatilho não era eficaz para o acionamento do cão. Porém, nos testes realizados nesta EPC, foi comprovado que um golpe com instrumento rígido no cão era capaz de acionar o pino percutor e assim causar um disparo". Assim a condenação pelo crime previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, é medida que se impõe.

Do mesmo modo, quanto ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a condenação é de rigor.

Partindo de tais premissas, nota-se que o conjunto probatório é suficiente para condenar o réu pela prática dos crimes descritos na denúncia. Isto porque, as declarações das testemunhas e a apreensão de grande quantidade de entorpecentes e arma na posse do acusado, demonstram a autoria delitiva.

O conjunto probatório produzido sob a garantia do contraditório judicial é harmônico com os elementos informativos colhidos na fase inquisitória, ambos indicando que o acusado tinha em sua posse os entorpecentes e munições descritos na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sabendo da sua destinação ao tráfico de entorpecentes.

Apurada a responsabilidade, passo a fixar a pena atendendo ao método trifásico da dosimetria em relação à prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 12, caput, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal:

Na primeira fase, nos termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observa-se que foi apreendida vasta quantidade e variedade de entorpecentes, entre os quais havia crack e cocaína (desta, mais de mil e setecentas porções), conhecidos pelo alto poder viciante e vulnerante. Além disso, observo que o réu cometeu o delito enquanto gozava de benefício processual, pois estava em liberdade provisória e delinuiu novamente pouco mais de um mês após sua soltura. Por essas razões, elevo a pena do crime de tráfico em  $\frac{1}{2}$ , e a do crime de

posse de arma em 1/3, fixando a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa, para o delito de tráfico e 01 ano e 04 meses de detenção, além de 13 dias-multa, para o delito de posse de arma.

Na segunda fase inexistem circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual reduzo as penas em 1/6, resultando as penas provisórias em 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa, para o delito de tráfico e 01 ano e 01 mês e 10 dias de detenção, além de 10 dias-multa, para o delito de posse de arma.

Na terceira fase, não há causas de aumento. Ainda nesta fase, inviável a aplicação do disposto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que o réu responde a processo por delito semelhante, supostamente praticado pouco tempo antes do delito tratado nestes autos, tendo o réu delinqüido no curso de sua liberdade provisória, quando se submetia ao dever de resguardo. Frise-se, ainda, que ele utilizava sua residência para armazenar grandes quantidades de entorpecentes e arma de fogo ilegal, sendo evidente a dedicação a atividades criminosas. Por isso, fixo a pena definitiva em 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa, para o delito de tráfico e 01 ano e 01 mês e 10 dias de detenção, além de 10 dias-multa, para o delito de posse de arma.

Diante do concurso material existente, nos termos do artigo 69 do Código Penal, opero a somatória das penas para atingir o montante de 06 anos e 03 meses de reclusão, 01 ano e 01 mês e 10 dias de detenção, além de 635 dias-multa.

Ante a ausência de informações da capacidade econômica do réu, fixo a valor de cada dia multa no mínimo legal.

Observando-se o disposto na súmula 719 do STF, para fins de estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena, anoto que o regime prisional adequado para início de cumprimento da censura penal deva ser o regime mais severo - fechado.

Isto porque, além da vultosa quantidade de entorpecentes apreendidos, o réu também mantinha em depósito arma de fogo. Assim, vislumbra-se que a culpabilidade do acusado extrapola aquela elementar à espécie.

Para o início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §3º do Código Penal, fixo regime FECHADO para a pena de RECLUSÃO, tendo em vista a pena fixada e o fato de o acusado estar sendo processado por outro crime de mesma natureza e as circunstâncias judiciais desfavoráveis; e regime SEMIABERTO para a pena de DETENÇÃO, tendo em vista a quantidade de pena aplicada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Para a aplicação da retratação penal do art. 387, §2º, CPP, necessário o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. No presente caso, inexistente prova do requisito subjetivo.

Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, Código Penal) e a aplicação do Sursis (artigo 77, Código Penal), ante a quantidade de pena fixada.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR o réu HERIK LEITE DOMINGOS à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial FECHADO; 01 ano e 01 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial SEMIABERTO, além de 635 dias-multa, no mínimo legal, em virtude da prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 12, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Presentes os pressupostos de manutenção da prisão cautelar, deve ser afastada a possibilidade de recurso em liberdade.

Assevere-se, nesse ponto, que o Supremo Tribunal Federal sufragou o entendimento de que "é pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar" (HC 89.824/MS, rel. Min. Carlos Britto, DJ 28-08-08). Nos mesmos moldes vem sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que assenta que "é incompatível com a realidade processual manter o réu preso durante a instrução e, após a sua condenação, preservado o quadro fático-processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade. Precedentes." (HC 289.217/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em

13/05/2014, DJe 21/05/2014).

Destarte, NEGO o direito de recorrer em liberdade ao réu.

Recomende-se ao estabelecimento prisional em que se encontrar recolhido e expeça-se, imediatamente, a respectiva Guia de Recolhimento Provisória.

Nos termos do artigo 63 e parágrafos da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do valor apreendido nos autos, bem como dos objetos relacionados no auto de exibição e apreensão.

DECRETO o perdimento dos objetos e valores apreendidos em favor da União.

Quanto à(s) arma(s) e as munições apreendidas, na medida em que não mais interessa(m) à persecução criminal e não foi(ram) reclamada(s), nos termos do artigo 509, § 3.º, das NSCGJ, determino o encaminhamento para destruição.

Custas ex lege.

Após o trânsito em julgado:

I) Comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da CRFB/88, bem como IIRGD.

II) Comunique-se o Juízo da Execução, para aditamento da Guia de Recolhimento, encaminhando-se as peças necessárias.

III) Tendo em vista a aplicação de pena de multa, feito eventual abatimento em caso de fiança recolhida (art. 479 das NSCGJ), expeça-se certidão de sentença do valor remanescente, de acordo com o modelo próprio do Sistema SAJ - Categoria 2 (Certidões), Modelo 505791, e abra-se vista ao Ministério Público, arquivando-se após os autos, com as anotações de praxe.

IV) oficie-se à autoridade policial para incineração da contraprova.

V) Oficie-se para que o banco depositário providencie a transferência do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas - Funad.

VI) Comunique-se o Sr. Escrivão Judicial, responsável pela Seção de Depósito e Guarda de Objetos, acerca do perdimento dos objetos apreendidos.

Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de praxe.

P.I.C.

Caraguatatuba, 15 de dezembro de 2022.

JÚLIO DA SILVA BRANCHINI

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA